

Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2019, n. 27977

Massime • 1

In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria. (Fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo).

Sul provvedimento

Citazione : Cass. pen., sez. III, sentenza 26/06/2019, n. 27977

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 27977

Data del deposito : 26 giugno 2019

Testo completo

279 77-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA LAPALORCIA Presidente- Sent. n. sez. 728/2019 -CC 04/04/2019 VITO DI NICOLA R.G.N. 51524/2018 CLAUDIO CERRONI EMANUELA GAI ALESSIO SCARCELLA ->Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO TE nato a [...] il [...] TO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PG, M. DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il congiunto ricorso;

\$ fer RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 13.11.2018, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'istanza proposta nell'interesse di CA ES e CA RM con cui le stesse avevano richiesto la revoca dell'ingiunzione a demolire, atteso l'intervenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Afragola (n. 1037 del 23.05.2016); giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che le istanze erano state condannate con sentenza della Corte d'appello di Napoli 16.10.1998, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all'art. 20, legge n. 47 del 1985, in relazione ad alcune opere realizzate senza titoli abilitativi, consistite in un fabbricato composto da pian terreno, primo e secondo piano su una superficie di mq. 220 per piano, ordinando la sentenza la demolizione delle opere abusive realizzate sino al 20.12.1993. 2. Contro la ordinanza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione le due istanze, a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un

unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 39, legge n. 724 del 1994. In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello di Napoli avrebbe errato nel non considerare l'orientamento ermeneutico formatosi in sede di legittimità relativamente all'art. 39 L. n. 724/1994. In particolare, trovando esso applicazione per le nuove costruzioni, si è ritenuto possibile calcolare la volumetria per ciascuna singola richiesta di concessione edilizia/permesso di costruire in sanatoria, così pre-supponendo la legittimità di una pluralità di domande per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda stessa (ad es. alienazione di una parte della costruzione). Da ciò deriverebbe che la concessione edilizia dovrà necessariamente essere unica per tutte le opere riguardando un edificio o un complesso unitario, non potendo lo stesso soggetto presentare separate domande per aggirare il limite di 750 metri cubi previsto dall'art. 39 suddetto. Diversamente invece potranno aversi una serie di istanze qualora esistano distinti titoli su singole porzioni (ergo vi siano più proprietari o soggetti aventi titolo al momento della domanda), dovendo la volumetria essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria. Perché ciò sia possibile, è indispensabile che l'immobile nel suo complesso risulti costituito da 2 singole unità catastali, ossia manufatti aventi specifica rilevanza quali distinte unità immobiliari autonomamente utilizzabili.

Ne consegue la possibilità di ottenere la sanatoria anche per immobili che complessivamente superino i 750 metri cubi, ma siano divisi in più unità non eccedenti tale volumetria e per ciascuna delle quali sia presentata una distinta domanda di condono. Le ricorrenti evidenziano inoltre come la Corte di Cassazione abbia riconosciuto come legittimati a presentare la domanda di condono non solo i titolari di un interesse giuridicamente protetto ma anche chi vanti un mero interesse di fatto alla regolarizzazione dello stesso. Richiamano ed allegano, a sostegno del ricorso, giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, unitamente all'atto di vendita del terreno dell'11.03.1992. 3. Con requisitoria scritta depositata in data 1.03.2019, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dott. M. Dall'Olio, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Si premette che nel caso in esame si controverte sull'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile di un fabbricato, sito nel comune di Afragola, composto da pian terreno, primo piano e piano secondo, con superficie di mq. 220 per piano, con volumetria eccedente i 750 mc. Tale immobile era stato successivamente oggetto del rilascio di sanatoria in data 23.05.2016, con richiesta di incidente di esecuzione per ottenere la revoca dell'ordine demolitorio emesso dal Pm in data 1.12.2015. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, evidenzia il PG, in base alle seguenti ragioni: a) erano state presentate tre differenti domande di condono, ciascuna relativa ad ogni singolo piano dell'immobile abusivo (da parte delle attuali ricorrenti nonché ad opera della figlia di CA RM), in modo tale da far sì che la volumetria concernente ogni singola richiesta fosse inferiore al limite massimo di 750 mc.; b) a fronte di esse veniva rilasciato un unico titolo abilitativo in sanatoria, ossia il permesso di costruire n. 1037 del 2016; c) ciò per il giudice dell'esecuzione realizzava una denuncia fittizia in quanto faceva apparire che le opere non fossero collegate tra loro allorquando le stesse risultavano invece finalizzate alla creazione di un unico manufatto con un'unica destinazione funzionale, ciò costituendo espediente non consentito. A sostegno della correttezza della soluzione del giudice dell'esecuzione, il PG ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, osservando come l'intervento edilizio abusivo è solo uno e, perciò, una sola può essere la richiesta di condono, atteso che una diversa opinione si farebbe strumento per la realizzazione, tramite dei frazionamenti, di un aggiramento della norma. 3 **fer** **CONSIDERATO IN DIRITTO** 4. Il congiunto ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

5. E' anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi le identiche doglianze difensive (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati,

che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

6. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto di dover sindacare la legittimità del titolo abilitativo in sanatoria, escludendo che allo stesso potesse essere attribuito effetto caducatorio dell'ordine di demolizione. Invero, la Corte ha rilevato la contrarietà alla legge dell'atto amministrativo in quanto successivo a tre distinte domande di condono, una delle quali presentata da Di SI AR ES (figlia di CA RM), non titolare di alcun diritto reale diversamente dalle sorelle CA ES e CA RM, proprietarie in regime di comunione indivisa del terreno sul quale era stato realizzato l'unitario fabbricato. Mediante tali istanze le stesse avevano fittiziamente realizzato un frazionamento dell'unico manufatto, funzionale ad un'unica costruzione, così da raggiungere una volumetria inferiore a 750 metri cubi (come richiesto dalla legge per la legittimità della singola domanda). L'illegittimità del permesso a costruire in sanatoria permetteva dunque di disconoscere l'effetto caducatorio dell'ordine di demolizione, confermandone l'esecuzione.

7. Trattasi di argomentazione del tutto corretta in diritto, che impone a questa Corte di fare chiarezza sulla questione giuridica controversa, afferente il tema della possibile frazionabilità della domanda di sanatoria. 4 Premessa fondamentale è la perimetrazione dei poteri del giudice penale rispetto al titolo abilitativo illegittimo, dovendosi precisare che anche con riferimento al permesso in sanatoria è da riconoscersi al giudice un potere-dovere di valutazione finalizzato, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, non tanto ad una valutazione di legittimità prodromica all'eventuale disapplicazione, quanto piuttosto, e precipuamente, ad una verifica della sussistenza effettiva dei presupposti, di fatto e di diritto, dai quali dipende l'estinzione del reato. Il giudice esercita in tale modo "un doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale" (Cass., Sez. III, 10 giugno 2008 n. 23080). Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve rammentarsi, quale presupposto indispensabile per il rilascio della sanatoria ex art. 13 L. n. 47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati, e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento in cui l'opera è stata realizzata sia in quello in cui la domanda è stata presentata. La L. n. 724/94, all'art. 39, comma 1, prevede la possibilità di ottenere la concessione edilizia in sanatoria c.d. speciale per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 le quali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto

superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive, realizzate nel termine di cui sopra, relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia. Si può, pertanto, affermare che il limite posto dal legislatore segna un vero e proprio discrimen tra opere ammesse e non ammesse alla sanatoria. La legge richiama il concetto di "unità immobiliare" con il quale è fatto riferimento alle singole opere abusive aventi specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili. La disciplina catastale la definisce come ogni fabbricato o porzione di esso, che presenta caratteristiche di autonomia funzionale ed in grado di produrre reddito da sola, nonché stabilmente fissa al suolo, anche se galleggiante o sospesa o semplicemente appoggiata purché stabilmente fissa al suolo, di qualsiasi materiale sia essa costituita e a condizione che risultino verificate le condizioni di funzionalità e reddito autonomi. Orbene, è ben vero che il legislatore non pone alcun divieto al frazionamento ovvero accorpamento di unità immobiliari, nel rispetto della normativa edilizia relativa. Tuttavia tali operazioni possono configurare ipotesi elusive dei limiti legali. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, norma in questione è da interpretare nel senso che ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario facente capo ad un unico soggetto legittimato, e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio 5 devono essere riferite ad una unica concessione in sanatoria, la quale dovrà riguardare lo stesso nella sua totalità. Ciò al fine di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera richiesto per la concedibilità della sanatoria. È quindi illecita la presentazione di più domande facenti riferimento a plurime opere le quali risultino artificialmente non collegate tra di loro sebbene, de facto, siano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto ed allo stesso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Cass., Sez. III, 8 aprile 2015, n. 20420; Cass., Sez. III, 19 aprile 2005, n. 20161). In merito sembra opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 302/1996) che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, L. n. 724/94, sulla premessa che il limite di 750 metri cubi trova un temperamento nelle nuove costruzioni, e solo per queste, ha spiegato che la possibilità, di natura derogatoria e quindi di stretta interpretazione, di calcolare la volumetria per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presuppone la sussistenza di ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda stessa per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria. Dunque, la regola è rappresentata dalla unicità della concessione edilizia per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, escludendosi la possibilità per lo stesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria per aggirare il limite

legale volumetrico. Di questa costituisce eccezione la presentazione di una serie di istanze da parte di quanti sono proprietari o soggetti aventi titolo al momento della domanda, avendo ciascuna di esse ad oggetto le sole porzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria. In tale ultima ipotesi la volumetria dovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria, non potendosi comunque superare il limite complessivo di 3000 metri cubi. (Cass., Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 21284). Analogamente si esprime la giurisprudenza amministrativa secondo la quale deve ritenersi illegittimo l'inoltro di diverse domande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, in quanto tale espediente rappresenta un evidente tentativo di aggirare i limiti consentiti per il condono relativamente al calcolo della volumetria consentita (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5211; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4483; Cons. Stato, Sez. VI, 05/09/2012 n. 4711). Dovrà quindi farsi riferimento all'unitarietà dell'immobile o del complesso immobiliare, ove sia stato realizzato l'abuso edilizio in esecuzione di un disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione dell'opera in più unità abitative, fatta salva l'ipotesi in cui porzioni della medesima costruzione costituiscano oggetto di diritto di diversi soggetti, ciascuno dei quali sarà legittimato a presentare istanza di sanatoria per la porzione allo stesso riferibile. Peraltro, la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la volontà del privato di considerare un'unità immobiliare autonomamente utilizzabile ed indipendente rispetto alle altre porzioni ed unità del medesimo fabbricato, non può influire sui criteri e sui limiti inderogabilmente fissati dall'ordinamento per la condonabilità dell'immobile abusivo, per modo che il frazionamento surrettizio di un immobile non può valere a sottrarlo al regime di condonabilità che gli è proprio. La valutazione deve essere effettuata sulla base della volumetria complessiva del manufatto, indipendentemente dal numero delle istanze di condono presentate. Infatti, va esclusa la possibilità di aggirare il limite volumetrico previsto mediante il fittizio frazionamento dell'immobile (da ultimo: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 03/09/2018, n.5317).

8. Trasponendo i principi supra illustrati alla fattispecie concreta oggetto di esame, il motivo si appalesa inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero, nonostante Di SI AR ES, in quanto figlia di CA RM, avesse un interesse giuridicamente rilevante alla presentazione della domanda di sanatoria, la posizione della stessa non può che ritenersi coincidente con quella della madre, considerato che il terreno sul quale il fabbricato era stato realizzato costituiva oggetto di proprietà in comunione indivisa con la sorella CA ES. Del resto, questa Corte ha di recente chiarito che in tema di condono edilizio, in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il

committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori (Nella fattispecie questa Corte ha escluso che i figli del proprietario siano legittimati a presentare detta istanza: Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 - dep. 04/07/2018, Quartucci, Rv. 273760). In ogni caso, nel caso di specie, dato il regime giuridico al quale il bene doveva ritenersi assoggettato, non essendo stata operata alcuna divisione né rinvenendosi un distinto diritto di proprietà (o ius in re aliena) su una porzione del fabbricato, le diverse domande devono tutte essere ritenute imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, con conseguente esclusione di un frazionamento, di fatto artificioso, mediante plurime istanze di condono. Di ciò, del resto, se ne trae conferma nello stesso provvedimento impugnato, laddove si evidenzia come ciascuna domanda di condono si riferiva ad ogni singolo piano dell'unico immobile abusivo, cui peraltro non corrispondono singole unità abitative, in quanto, si legge nell'ordinanza, al primo ed al secondo piano vi sono due appartamenti a piano, ciò che 7 pertanto conferma la correttezza dell'approdo valutativo del giudice dell'esecuzione, che ha concluso nel senso che la presentazione delle tre separate istanze di condono si

risolveva in una denuncia fittizia per opere non collegate tra loro, laddove invece le stesse risultavano finalizzate alla creazione di un unico manufatto funzionale ad un'unica costruzione.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del congiunto ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 aprile 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Grazia Lapalorcia Alessia Scarcella ГОРХОЧЕЕ DEPOSITATA INCE 26 GIU 2019 IL CANCELLIERE mi Tuana 8